

Isenção de tributação de NFTs – um convite à evasão fiscal

A entrada em vigor da Lei do Orçamento do Estado para 2023 (LOE 2023) trouxe a primeira abordagem da legislação fiscal portuguesa à tributação de operações com criptoativos, passando a existir uma definição fiscal de criptoativos e regras específicas sobre esta matéria, com especial enfoque no IRS.

A legislação fiscal agora publicada dispõe, no seu artigo 10.º, n.º 17, do CIRS: "*Para efeitos do presente Código, considera-se criptoativo toda a representação digital de valor ou direitos que possa ser transferida ou armazenada eletronicamente recorrendo à tecnologia de registo distribuído ou outra semelhante*", mas exclui claramente os NFTs na norma imediatamente subsequente: "*Excluem-se do disposto no número anterior os criptoativos únicos e não fungíveis com outros criptoativos*"¹.

Ora, como sabemos, "o contribuinte é como a água", adaptando-se à mais pequena fissura na legislação fiscal para conseguir contribuir o mínimo possível. Todavia, *quid juris* quando não estamos perante uma fissura, mas sim uma verdadeira porta à evasão fiscal e ao branqueamento de capitais, por incompetência do legislador?

Em termos (demasiado) simplistas, é muito fácil branquear capitais através de NFTs, licitamente, de acordo com a lei do IRS vigente.

Imaginemos a seguinte hipótese:

- O Senhor A deposita 1000 euros na *Binance* (uma CEX).
- Com esses 1000 euros, compra o equivalente em ETH, sensivelmente 0,6 ETH.
- Com esses 0,6 ETH, o Senhor A transfere o *ether* para uma *self custody wallet*, abrindo e fechando algumas posições numa DEX como a *Uniswap*.
 - Aqui bifurcamos:
 - **Cenário 1** – Trades com lucro – os 0,7 ETH transformam-se em 1,2 ETH.
 - **Cenário 2** – Trades com prejuízo – os 0,7 ETH transformam-se em 0,4 ETH.

¹ A redação da norma é elusiva - "Alienação onerosa de criptoativos que não constituam valores mobiliários." - como é que é possível existir uma alienação onerosa de criptoativos que constituam um valor imobiliário?

Cenário 1 – Trades com lucro

- De acordo com a lei vigente, será uma mais-valia mobiliária, nos termos do artigo 10.º, n.º 1, alínea k), ex vi artigo 9.º do CIRS. O valor de realização da mais-valia será de 0,5 ETH, que será tributado a uma taxa proporcional especial de 28% (artigo 72.º, n.º 1, do CIRS).
- Para efeitos de liquidação do imposto, o ETH terá de ser trocado por moeda corrente. Os 0,5 ETH serão vendidos no mercado e transformados em 710 euros.
 - Logo aqui temos uma violação do princípio da tipicidade - o trâmite "venda no mercado" não está expressamente definido na lei.
 - Assumindo que esta lacuna não existe e que se encontra especialmente previsto o trâmite da "venda no mercado":
- $710 \times 0,28 = 198,8$ euros de imposto a pagar.

Agora, a arquitectura do branqueamento de capitais lícito.

- Voltemos uns passos atrás:
 - No momento em que temos 1,2 ETH (trade com lucro), compramos um NFT por esse valor (basta abrir o *OpenSea* e escolher esse preço).
 - Neste caso, não se realizou qualquer mais-valia.
 - Utilizaram-se 0,7 ETH para auferir 1,2 ETH, e esse valor foi utilizado para comprar um NFT, que não foi trocado por euros directamente.
 - De acordo com a lei fiscal actualmente em vigor, não haverá tributação quando a contraprestação das alienações assuma a forma de criptoativos, atribuindo-se aos criptoativos recebidos o valor de aquisição dos criptoativos entregues. Em termos simples, a permuta de criptoativos por criptoativos não é tributada.
 - Princípio da tipicidade fechado- na ausência de norma de incidência, não se tributa.
 - Ora, na alienação do NFT para ETH, realizar-se-á a mais-valia de 0,5 ETH.
 - Assim sendo, a conversão destes 0,5 ETH para 710 euros não pagará imposto, por falta de norma de incidência (poupando 198,8 euros).

Cenário 2 – Trades com prejuízo

- Os 0,7 ETH transformam-se em 0,4 ETH.
- Estamos perante uma perda; não se realizou qualquer mais-valia.
- A categoria G prevê a tributação do saldo positivo resultante do valor de realização da mais-valia. Assim sendo, está isento de tributação.

Cenário 3 – HODL

- Imaginemos agora a situação em que os 0,7 ETH estão parados e continuamos com 0,7 ETH; todavia, o preço do ether subiu e 0,7 ETH já não vale 710 euros. Vale 1000 euros.
 - Neste caso, o valor de realização será de 290 euros, no momento da troca para euros.
 - Este ganho de 290 euros será tributado a 28%, resultando em 81 euros.

Todavia, pode não trocar para euros e comprar um NFT no valor de 0,7 ETH. Como mencionei acima, a categoria G tributa alienações e, na ausência de norma de incidência, não se tributa. Assim sendo, ao vender o NFT de 0,7 ETH e, subsequentemente, trocá-lo por 1000 euros, esta alienação fica isenta de tributação.

Poderia explicar por que razão as leis em vigor de determinado Estado não importam, por serem inexecutáveis (deixando isso para outras sedes), mas, admitindo que ainda recai sobre o "monopólio da força" do Estado esta tributação, o atual mecanismo permite, licitamente, não ser tributado.

Não obstante, utilizei 1000 euros a título exemplificativo. Imagine-se a perda de receita estadual através deste mecanismo com outras quantias. Imagine-se a situação em que um trabalhador prefere receber parte do salário em crypto e o remanescente (declarando o salário mínimo) em euros.

É possível, de acordo com o IRS vigente, um trabalhador receber "de facto" 4000 euros, declarar "de jure" o salário mínimo de 760 euros, pagar a taxa progressiva correspondente - e não tributar 3240 euros, através deste mecanismo. É dinheiro limpo e lícito.

O crime de branqueamento de capitais na aceção do artigo 368.º-A do Código Penal

De forma sucinta, podemos afirmar que o crime de branqueamento de capitais consiste na conversão, transferência, auxílio ou facilitação de alguma operação de conversão ou transferência de vantagens, obtidas por si ou por terceiro, direta ou indiretamente, provenientes da prática de um determinado conjunto de ilícitos criminais (também designados como crimes precedentes), com o objetivo de dissimular a proveniência ilícita dessas vantagens ou de evitar que o autor ou participante dessas infrações seja criminalmente perseguido ou submetido a uma reação criminal.

Também é considerado crime de branqueamento a ocultação ou dissimulação da verdadeira natureza, origem, localização, movimentação ou titularidade das vantagens provenientes da prática de crimes precedentes ou dos correspondentes direitos.

QUESTIONO – SERÁ O PLANEAMENTO FISCAL ASSIM ARQUITETADO, COMO FACTO JURÍDICO, UM FACTO CRIMINALMENTE TÍPICO?